

1501425-27.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... motivo da abordagem se deu pelo intenso tráfico no local; que a equipe foi até o local e encontrou o réu em flagrante delito de tráfico, como acontece rotineiramente no local.

A testemunha de defesa Cleyvison José Moreira Moraes, em juízo, respondeu que era ele quem estava com a sacola de entorpecentes e que o tráfico no local era distribuído em horários e naquele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501425-27.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501425-27.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115878/2022 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 24620134 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2115878 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN FRANÇA GAMA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

NATHAN FRANÇA GAMA DA SILVA, menor de 21 anos, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 28 de abril de 2022, às 23h10min, na Rua Valter Dester, 432, Parque Residencial das Andorinhas, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, o denunciado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros 57 gramas de cocaína, distribuídas em 88 supositórios, 39 gramas de crack, distribuídos em 86 pedras e 110 gramas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, distribuídos em 96 invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$137,60.

Na audiência de custódia foi convertida a prisão flagrante em prisão preventiva

(fls. 51/53).

Às fls. 71 foi determinada a notificação do réu, efetivada às fls. 76.

Resposta à acusação (fls. 80/93).

A denúncia foi recebida em 06 de junho de 2022, ocasião em que foram afastadas as preliminares arguidas em sede de defesa prévia (fls. 141/142).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, uma da defesa e, por fim, o réu foi interrogado (fls. 199).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, manifestou-se pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa Técnica do acusado alega, em preliminar, nulidade da prisão realizada por guardas municipais; ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio em audiência. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta pois o réu não chegou a praticar o delito de tráfico pugnando pela absolvição do réu no art. 386, inciso III, do CPP. Em caso de condenação, requer a aplicação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea; o afastamento da causa de aumento de pena pelo crime ter envolvido adolescente; a aplicação da causa de redução da pena em grau máximo; o regime aberto para cumprimento da pena; a substituição por restritivas de direito; e que o réu possa recorrer em liberdade (fls. 200/221).

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilegal de entorpecentes envolvendo adolescente. Inicialmente, passo a apreciação das preliminares de defesa arguidas em sede de memoriais.

A preliminar de nulidade da prisão pela atuação por guardas municipais já foi apreciada pela decisão de fls. 141/142.

Quanto a tese de nulidade do interrogatório judicial por ausência de advertência ao direito ao silêncio do réu em juízo, não prospera porquanto trata-se de nulidade relativa que pressupõe efetiva comprovação de prejuízo ao réu, o que não restou comprovado na presente hipótese.

Nesse sentido é o entendimento pacificado da jurisprudência pátria: (HC n. 52.370/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 9/5/2006, DJ de 5/6/2006, p. 304.) e (TJSP; Apelação Criminal 1501162-64.2019.8.26.0559; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2021; Data de Registro: 16/09/2021).

Portanto, ausente demonstração de prejuízo efetivo ao réu, não há que se falar em nulidade do interrogatório.

Superada a preliminar, no mérito, a pretensão punitiva estatal procede.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 04), o boletim de ocorrência (fls. 15/19), o auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), o auto de constatação preliminar (fls. 14), o laudo pericial (fls. 172/174), bem como as provas orais coligidas.

A testemunha em comum e guarda municipal, Victor Augusto Santos Costa, em Juízo, narrou que estava em patrulhamento pelo local conhecido pelo intenso tráfico e lá visualizou quatro pessoas, sendo uma delas o réu, outra o adolescente Cleyvison e dois usuários que estavam no local para comprar drogas, mas não chegaram a efetuar a compra diante da chegada dos policiais. Disse que abordou o réu, já conhecido por outras abordagens relacionadas com entorpecentes e com o réu encontrou uma sacola com os entorpecentes e com o adolescente a contabilidade da biqueira e quantia em dinheiro. Disse que o adolescente relatou que as drogas e o dinheiro eram para o tráfico. Respondeu que teve acesso ao beco, local em que foi abordado o réu, pela via pública; que após a abordagem do réu a viatura chegou em dois minutos pois

estava próxima ao local; que foi a pé até o beco porque assim não seria visto pelos olheiros do tráfico, pois a viatura acusaria a presença dos policiais. Seguindo a mesma diretriz, foram as palavras da testemunha em comum e também guarda municipal, Eliseu Mendes Moreira. Respondeu que teve acesso ao beco a pé; que a viatura estava perto do local; que os dois usuários não chegaram a comprar os entorpecentes, mas confirmaram que iriam fazê-lo; segundo a testemunha a sacola estava nas mãos do réu; que o motivo da abordagem se deu pelo intenso tráfico no local; que a equipe foi até o local e encontrou o réu em flagrante delito de tráfico, como acontece rotineiramente no local.

A testemunha de defesa Cleyvison José Moreira Moraes, em juízo, respondeu que era ele quem estava com a sacola de entorpecentes e que o tráfico no local era distribuído em horários e naquele horário era o declarante o responsável pelo tráfico; que os guardas acessaram o local pela mata; que a viatura demorou uns de 10 a 15 minutos para chegar ao local; não confirmou que a sacola ficava no chão conforme havia relatado na delegacia de polícia, asseverando que estava com a sacola das drogas nas mãos; que deu versão divergente na delegacia porque estava muito nervoso e afirmou em juízo que o réu ia apenas comprar uma porção de maconha. O acusado, em seu interrogatório, negou a autoria dos fatos. Afirmou que no dia havia acabado de descer ao local e pediu um "beck" para o adolescente porque iria assumir o turno do tráfico naquela noite, mas foi surpreendido pela presença dos policiais. Já teve envolvimento com o tráfico na adolescência e que não tem nada contra os policiais. Respondeu que já havia pago pela drogas; que entregou cinco reais ao adolescente; que é usuário de drogas e foi ao local comprar maconha e estava conversando com o adolescente para assumir o turno do ponto de vendas porque estava sem dinheiro, mas não chegou a assumir o ponto; que a guarda veio pela mata; que havia acabado de descer ao local quando a guarda chegou; que não chegou a pegar a sacola com as drogas; que fica na venda das drogas uma pessoa por turno. Em que pese a negativa de responsabilidade pelo crime esta veio desacompanhada de provas. O réu apresentou versão frágil e pueril, cuja veracidade não foi capaz de comprovar, como lhe competia, nos termos do que prevê o art. 156 do Código de Processo Penal e, portanto, tal versão não deve prevalecer quando em confronto com as provas produzidas nos autos, restando sua negativa isolada do conjunto probatório.

Aliás, acatar a falaciosa fala do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos guardas municipais, com o intuito exclusivo de incriminar pessoa que sabiam ser inocente e, da mesma forma, sem a mínima comprovação.

É sempre bom consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente. Como qualquer testemunha, eles prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada existindo prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

No tocante ao depoimento de agentes da Lei, o Egrégio Tribunal tem entendido: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286).

Nesse sentido não prospera a tese da Defesa Técnica sob o argumento de atipicidade da conduta, sustentando que o réu não chegou a praticar o delito de tráfico pois havia ido até o local comprar uma porção de maconha e se ofereceu ao adolescente para assumir o próximo turno do tráfico, mas não chegou a assumir o turno. A única prova que possui para sustentar essa versão é a declaração em juízo do adolescente envolvido no tráfico em divergência com o seu relato na fase policial. O adolescente, na delegacia, afirmou que estava vendendo drogas na companhia do réu e era o responsável por realizar o recolhimento do dinheiro (fls. 10), o que enfraquece sobremaneira sua versão prestada em juízo, a qual tem o nítido objetivo

de inocentar o réu.

Por outro lado, a versão dos guardas municipais de que flagraram o réu com a sacola de drogas nas mãos, restou corroborada pela versão do usuário Marcos que estava no local para adquirir drogas e relatou em solo policial que quem estava na venda dos entorpecentes era o réu, o qual portava uma sacola plástica e junto dele havia outro homem (fls. 08).

Reforçando essa tese, em uníssono, os guardas municipais declararam que ao adentrar ao beco surpreenderam o réu com a sacola de drogas nas mãos e com o adolescente Cleyvison o dinheiro apreendido e a contabilidade da biqueira, assim, não resta dúvida que a autoria do delito de tráfico recai sobre a pessoa do acusado.

Outrossim, também restou incontroverso que o crime praticado pelo acusado envolveu adolescente, uma vez que ambos foram flagrados em efetiva traficância, cabendo ao réu entregar a droga e ao adolescente recolher o dinheiro da compra dos entorpecentes, devendo assim, o réu se submeter ao aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de constatação e pelo laudo de substância psicoativa (fls. 172/174), segundo o qual as substâncias apreendidas tratavam-se de entorpecentes.

Já a autoria restou presente uma vez que os ilícitos foram encontrados na posse do acusado, conforme prova oral produzida sob o manto do contraditório e ampla defesa, a qual não foi afastada ante a ausência de provas em sentido contrário.

A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas tornam irrefutável a conclusão de que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, o acusado trazia consigo, para venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade." (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária, inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória, conforme requer a Defesa Técnica.

Outrossim, inviável o reconhecimento de atipicidade da conduta do réu sob o argumento de que ele pretendia assumir o turno do tráfico no local mas não chegou a fazê-lo porque surpreendido com a presença dos agentes policiais, porquanto, conforme já explanado, o réu estava em efetivo tráfico de entorpecentes quando abordado pelos guardas municipais.

Portanto, a conduta por ele praticada encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, no tocante ao delito de tráfico, nos termos do artigo 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, ou seja, em CINCO ANOS de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, deixo de calcular o decréscimo que decorreria da menoridade penal (art. 65, I, CP) porquanto a atenuante não pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo, 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pois a prática do crime atingiu adolescente, razão pela qual aumento a pena em 1/6 o que resulta em CINCO ANOS e DEZ MESES de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Em seguida, em que pese a não reincidência e a primariedade técnica do acusado, as anotações de inúmeros atos infracionais análogos ao tráfico (fls. 102/110) permitem concluir que o réu se dedicava a atividades criminosas, afastando assim a aplicação

do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido, recente julgado do E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no HC 609.022/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). grifei

Por outro lado, tratando-se de réu tecnicamente primário, menor de 21 anos e a quantidade de pena aplicada, mostra-se viável a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, contudo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes – Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Réu que, embora primário, esteve envolvido em atos infracionais análogos ao tráfico – Indicação de que faz do crime seu meio de vida – Benefício incabível; Tráfico de entorpecentes – Pena superior a 4 anos – Réu primário e menor de 21 anos – Regime semiaberto – Cabimento -- Substituição por restritiva de direitos – Impossibilidade – Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 1500249-82.2020.8.26.0580; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cândido Mota - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 22/03/2021). grifei

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o denunciado NATHAN FRANÇA GAMA DA SILVA, menor de 21 anos, ao cumprimento das penas de CINCO ANOS e DEZ MESES de reclusão, em regime inicial semiaberto e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, por infração ao artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Determino, ainda, o perdimento definitivo dos valores apreendidos obtidos com a traficância, nos termos do artigo 91 II, “b”, do Código Penal, e do artigo 62 da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

O acusado foi preso em flagrante, teve sua prisão convertida em preventiva e assim vem respondendo aos autos, não poderá, portanto, recorrer em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA